

1500108-22.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500108-22.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018666/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22562076 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 159/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2018666 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

GABRIEL CRISTOFOLI e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

30/03/2022

Réu Preso

Em 30 de março de 2022, às 15:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DRA. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus GABRIEL CRISTOFOLI e MIZAELE DE SOUZA FIDÊNCIO, bem como suas Defensoras Técnicas, DRA. Telma Romilda de Almeida OAB 81787/SP e DRA. Sueli Maria Campregheer OAB 184869/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM), Daniel da Silva Martino (GCM), Sueli Rosa F. Mariano, Evelin Cristina Martins e Ciro de Sousa Fidêncio. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com suas Defensoras. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis

que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. GABRIEL CRISTOFOLI e MIZAE DE SOUSA FIDENCIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Legal, eis que no mês de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime de tráfico. E no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 18h20, na rua Jorge Salum, altura do nº 200, bairro Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 12 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 9,5 gramas e 09 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denuncia ter sido apurado que os denunciados praticavam o tráfico no bairro Jardim Rosa Garcia, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, as drogas ficavam escondidas na viela, junto a uma pilha de tijolos, para onde GABRIEL se dirigia, a fim de buscar e repassar a MIZAE, que promovia as vendas aos usuários. O dinheiro recebido por MIZAE era entregue a GABRIEL, responsável pela guarda. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de que os denunciados estavam praticando o comércio ilegal. A informação dava conta das vestes, do local onde as drogas eram mantidas, bem como acerca da dinâmica empregada pelos denunciados. Os agentes públicos se dirigiram ao endereço e avistaram GABRIEL deixando a viela, com algo em mãos, indo na direção de MIZAE. Em seguida, sem perceberem a presença dos guardas, os denunciados trocaram objetos. Houve a abordagem, oportunidade em que MIZAE dispensou 09 porções de cocaína no chão. Em revista pessoal, com GABRIEL foram encontrados R\$ 210,00 e, com MIZAE, a quantia de R\$ 10,00. Na viela, junto aos tijolos, foram encontradas mais 12 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas com os denunciados. A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pela quantia em dinheiro e em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante. Os crimes foram praticados em ocasião de calamidade pública decorrente da Pandemia Covid-19 (Decreto Legislativo nº 6/20 e Decreto Estadual nº 64.879/20). Os réus foram notificados (fls. 144 e 155) e apresentaram defesas previas de fls. 159/160 e fls. 161. A denuncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 164). Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas da acusação e da defesa e interrogado os réus. O Ministério Público ofereceu alegações orais nos termos da denuncia e a defesa requereu pela improcedência por falta de provas. FA e certidões de fls. 42 a 53. É o resumo do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se o réu da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não

se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...) (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...) (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...) (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e a adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 131/135) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu Mizael em solo policial (fls. 04) declarou "que estava fazendo uso de entorpecente quando um conhecido pediu para que o interrogado buscasse oito porções de cocaína. O interrogado recebeu R\$ 300,00 e foi até o local dos fatos para adquirir o entorpecente.

Chegando no local fez contato com um indivíduo que entrou na viela e logo esse indivíduo voltou e lhe entregou as oito porções de cocaína. Logo em seguida foi abordado pelos GCM's. Conhece o outro indiciado de vista, e afirma que não foi ele que lhe forneceu o entorpecente". Em juízo o réu disse que não é traficante, que é usuário, que estava na linha fazendo uso de crack quando chegou um indivíduo e lhe ofereceu dez reais, caso ele buscasse um pó para ele. Ele deu o dinheiro do po, uns duzentos reais, e mais um pouco para ele comprar cigarro e uma pedra. Não se recorda quem foi o indivíduo que entrou na viela e buscou a cocaína. Não olhou para aparência da pessoa que lhe entregou a droga. Pegou a droga e saiu ligeiro. Seu bolso estava furado, não tentou dispensar o entorpecente. Nega que tenha dito que

estava traficando e que Gabriel era o responsável pela coleta do dinheiro e entrega da droga. É usuário de crack. Nunca foi internado, pois não aceitava ser tratado e não fez tratamento. Já foi processado. Trabalhava com seu pai e as vezes com seu sogro. Não prestou atenção na abordagem de Gabriel, e não escutou nenhuma ameaça dele. Foi uma pessoa desconhecida que lhe entregou o dinheiro, na confiança. O réu Gabriel em solo policial (fls. 05), declarou "estava dentro de um bar para comprar bebida, com o dinheiro que obteve com a sua companheira, quando foi abordado pelos GCM's. Sendo que nada de ilícito foi encontrado com o interrogado, somente dinheiro, R\$ 210,00. Conhece o outro indiciado faz tempo, desde a infância, mas não sabia que ele estava com entorpecente. Viu quando o outro indiciado, Mizael, dispensou o entorpecente no chão. Nega que estivesse na posse de entorpecentes, ou que estivesse traficando no local. Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que quando o fato ocorreu estava no bar comprando cerveja, o policial veio e lhe grudou pelo braço e quando ele olhou para trás tinha umas drogas no chão. Mostrou o aplicativo do auxílio que estavam recebendo. Conhece os guardas municipais de quando era menor de idade e acredita que eles o perseguem por causa de suas passagens quando menor. Não estava junto com Mizael, estava dentro do bar, estava longe dele. Nega que estivesse abaixado ao lado de uma pilha de tijolos. Não escutou Mizael confessando e não o ameaçou. Nega que atuasse como um gerente do trafico. Esta desempregado e recebe auxílio. Não tem filhos e nunca foi processado. Foi abordado dentro do bar e havia outras pessoas no local. Verifica-se que os réus ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa negaram o envolvimento com o trafico de entorpecentes. Embora Mizael admita o porte de 09 porções de cocaína que comprou para um desconhecido, negou que estivesse realizando a venda de entorpecentes, negou o envolvimento com Gabriel e negou ter feito a confissão informal dos fatos. Ocorre que suas versões restaram inconsistentes e isoladas das demais provas dos autos. Alias o corréu Gabriel afirmou ter sido abordado no interior de um bar, sem trazer uma única testemunha que pudesse confirmar sua versão. O Guarda Civil Municipal DANIEL DA SILVA MARTINO, em sede policial (fls. 02), relatou que, na data dos fatos, "em patrulhamento de canil pelo rairro rosa Garcia 2 , fomos solicitado por um morador que nos informou que um rapaz com camisa do corinthians chamado Gabriel guardava drogas em uma viela pela rua Jorge Salum em uma pilha de tijolos e saia para entregar a droga a um outro rapaz de blusa azul e fazia a recolha do dinheiro, e esse rapaz de blusa azul vendia a usuários. de posse das informações adentramos a referida rua , e avistamos Gabriel saindo da viela com algo nas mãos e não nos viu e na altura do numeral 200 pegou algo de Mizael e colocou no bolso da bermuda e entregou algo a Mizael, ato contínuo ambos foram abordados e no momento da abordagem Mizael veio a soltar 09 porções de cocaína (tipo aricanduva). Em revista pessoal com Gabriel foi localizado R\$ 210 reais em dinheiro e com Mizael R\$10 reais em dinheiro. Foi solicitado apoio da viatura Romu 07, e foi vistoriado a viela da denuncia que saiu Gabriel, onde foi localizado em uma pilha de tijolos 12 porções de cocaína (tipo aricanduva) idênticas as localizada com os indiciados; ainda, não havia mais ninguém próximo à eles na viela". Em juízo declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro, conhecido pelo alto índice de trafico, foram abordados por um cidadão moreno, grisalho que descreveu dois indivíduos, as vestimentas e com eles agiam, que um pegava o entorpecente e entregava para o outro. Foram ao local apontando viram que os réus entregaram algo um para outro. Mizael dispensou algo, que depois se verificou tratar de 09 porções de cocaína do tipo Aricanduva. Próximo ao local que Gabriel estava abaixado havia uma pilha de tijolos e ali estavam escondias mais 12 porções. Mizael acabou por confessar os fatos, disse que estava enfrentado dificuldades e que Gabriel recolheu o dinheiro e funcionava com um gerente. As drogas encontradas na pilha de tijolo e as dispensadas por Mizael eram idênticas, cocaína do tipo Aricanduva. Já havia varias denuncias acerca dos réus, mas não lograram êxito na abordagem. Nessas denuncias Gabriel sempre foi mencionado, já Mizael deduziam pelas características físicas e porque ele tem envolvimento com o trafico. Gabriel seria o gerente, responsável pela entrega da droga e recolha do dinheiro. Não havia outras pessoas no local. Gabriel permaneceu silente. Não aparentavam ter feito uso de entorpecentes, não alegaram que a droga era para uso e não tinham apetrechos destinados ao uso da

droga. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, relatou que houve uma denúncia para o pessoal do canil, que entrou em contato com eles, de que um transeunte relatou que um indivíduo de nome Gabriel com camiseta do Corinthians e outro indivíduo Mizael estavam realizando o tráfico e que Gabriel utilizava uma viela para guardar os entorpecentes. No local o GCM disse que viu Gabriel abaixado perto de uma pilha de tijolos e que ele entregou algo para Mizael. Já Mizael teria dispensado algo, que verificou-se tratar de 09 porções de cocaína e na pilha de tijolos foram encontradas mais 12 porções, idênticas as dispensas por Mizael. Quando Mizael confessou os fatos, Gabriel disse para ele ficar quieto e “que colocaria uma marcha em sua família”, demonstrando que haveria uma hierarquia entre um e outro. A quantia maior de dinheiro estava com Gabriel. Não havia outras pessoas no lugar. Não encontraram objetos de uso pessoal de Mizael para uso da droga. Mizael aparentava estar normal, Gabriel também. Sobre os réus já recaíam denúncias e depois que Gabriel foi liberado na audiência de custódia, sobreveio nova informação. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas 2) a existência de denúncia anônima que apontou as características físicas, vestimentas e locais que os réus estavam desenvolvendo o tráfico e 3) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 131/135), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem,

em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a conduta dos acusados Mizael e Gabriel que repassaram algo um ao outro, sendo que após Mizael dispensou as 09 porções de cocaína, 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 5) a

localização dos acusados em local conhecido pela traficância. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. As testemunhas de defesa em nada sabiam sobre os fatos. A testemunha Suely disse que é tia da esposa do réu, que ele é usuário, mas, não sabe se ele já procurou tratamento. Ele trabalhava como ajudante do pai e as vezes ajuda a esposa no ferro velho. Tem uma vida bem sofrida. A testemunha Evelin disse que viu o réu apenas depois que ele já havia sido abordado. No local desconhece a existência de ponto de trafico. Conhece Mizaél desde criança e ele trabalha com o pai como ajudante de pedreiro. Sabe que ele é usuário de crack. Não sabe a quanto tempo ele estava em liberdade, pois não o via muito. Não sabe sobre os outros processos. Não usa entorpecentes. Quando passava na linha via o réu usando algo,

mas ele escondia a droga. Não conhece Gabriel. A testemunha Ciro, irmão do réu, foi ouvido sem compromisso. Seu irmão é usuário de crack há 2, 3 anos. Já tentaram tirar o réu da droga, o pegavam na linha, tentaram internação compulsória, mas ele não ia. Ele trabalha dia de semana com seu pai, não ganhava dinheiro com o tráfico. O réu as vezes pedia para ele servir de mula para pegar a droga na biqueira e daí ele ganhava alguma porção. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 155/159) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo–, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Réu MIZAEI. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, eis que o réu ostenta várias condenações, ocorre que apenas uma delas geradora de reincidência e as demais ainda não definitivas. Desta feita, por ora, fixo o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Proc. nº26/36.2020, fls. 44), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de evidente personalidade transgressora, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel.

Des. ALBERTO

MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). B - Réu Gabriel: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em que pese ostentar o réu inúmeras passagens pela vara da infância e juventude, entendo que ainda faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que incidirá no patamar de metade, tendo em vista o concurso de agentes para prática delitiva e a nocividade do entorpecente traficado (cocaína), fixando-se a pena em 2(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, considerados os motivos acima expostos, o que também servirá para impedir a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para 1) condenar os réus MIZAE DE SOUSA FIDENCIO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e GABRIEL CRISTOFOLI, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 250 (duzentos e cinquenta dias multa), com valor unitário no mínimo legal e 2) absolve-los da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu MIZAE, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando a habitualidade criminosa revelada em inúmeros processos e sua reincidência específica, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Em relação ao corréu GABRIEL, defiro apelo em liberdade eis que respondera solto ao processo sem intercorrências.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento os réus de custas judiciais concedendo-lhes a gratuidade da justiça. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente a pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 220,00 em dinheiro - fls. 9), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Pelas Defensoras dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelos réus, saindo Defensoras, desde já, intimadas a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se as competentes certidões de honorários (fls. 146/147). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA